

1510398-58.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY RODRIGO DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

WESLEY RODRIGO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510398-58.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510398-58.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY RODRIGO DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

WESLEY RODRIGO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 02 de maio de 2022, por volta das 21 horas, na Avenida Jornalista Roberto

Marinho, nº 10, Campo Belo, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) porções de ADB-Butinaca, substância conhecida como K2, pesando 4,4 g (quatro gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, o acusado apresentou Defesa Prévia, subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos (págs. 84/85).

Recebida a denúncia (págs. 87/90), o acusado foi citado (págs. 104/105).

Realizada audiência de instrução e julgamento nesta data, foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição e sustentou, em síntese, precariedade probatória. Alternativamente, pleiteou : I- fixação da pena base no mínimo legal; II - desclassificação do crime denunciado para a figura típica prevista no artigo 28 da lei 11.343/06; III - aplicação do redutor de pena previsto no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas; IV - detração; V - fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; e, por fim, V - seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 04 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 06/07); auto de exibição e apreensão (pág. 10); laudo de constatação (págs. 12/14); laudo pericial de exame químico-toxicológico encartado às págs. 69/71, que resultou positivo para ADB-Butinaca; bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado nada declarou, e optou por permanecer em silêncio (pág. 17).

Em juízo, já sob o crivo do contraditório, negou o cometimento do crime que lhe foi imputado na denúncia.

Disse que foi flagrado por policiais militares quando portava as drogas relacionadas na denúncia - 29 porções. Entretanto, negou a finalidade mercantil do entorpecente, afirmando que destinava-se ao seu próprio consumo.

Narrou que no dia dos fatos havia retornado do aeroporto de Congonhas, local onde trabalha engraxando sapatos - "...eu, meu irmão e esse outro menino engraxa lá...". Foi até sua residência, deixou a quantia de R\$100,00 com sua genitora e ficou com R\$45,00.

Disse que os outros meninos o acompanharam até o ponto de tráfico. Entregou ao traficante R\$45,00 e os outros meninos R\$50,00, cada um. Logo que comprou os entorpecentes, foi surpreendido por policiais.

Justificou que não correu porque portava as drogas para consumo.

Esclareceu que o traficante estava no interior de um veículo, e deixou o local quando os policiais se aproximaram.

Foi revistado, os policiais encontraram as drogas em seu poder, e o levaram para a delegacia de polícia para averiguação.

Referida versão não é merecedora de nenhuma credibilidade, restou isolada nos autos, e veio desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutada cabalmente pela prova adversa - notadamente pelo firme relato das testemunhas policiais, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante que realizaram -, comprometendo sobremaneira o réu.

Assim é que os policiais responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram inquiridos, apresentaram esclarecimentos harmônicos a respeito do fato criminoso aqui tratado.

Narraram que patrulhavam pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, e visualizaram três indivíduos, dentre eles o acusado.

Notaram que havia um carro parado, o acusado foi até um dos ocupantes, e viram que houve gesto de troca entre eles.

Optaram pela abordagem e localizaram os entorpecentes em poder do acusado, mais precisamente nas vestes dele.

Questionado, informalmente, o acusado confessou que promovia a mercancia no local, ainda lhes informou que havia mais drogas e armas na comunidade. Desta forma, vistoriaram o local por ele indicado, mas não localizaram qualquer substância ilícita.

Acrescentaram que os indivíduos que estavam próximos ao acusado negaram a prática do tráfico e não portavam drogas.

Diante de tais circunstâncias, proferiram voz de prisão em flagrante ao réu, que mais tarde foi ratificada pela Autoridade Policial.

Como consignado, a prova produzida no contraditório bem demonstrou a ocorrência do delito, sendo incontroversa a autoria.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado nada declarou e optou por permanecer em silêncio. Embora direito assegurado pela Constituição Federal, não é postura compatível a situação de pessoa inocente, frente a prisão injusta.

Nesse sentido: "(...) embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável aos réus, por a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em juízo" (Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 11ª Câmara, Ap. nº 1.047.891, Relator Renato Nalini).

Razoável mesmo supor que, estivesse sendo vítima de prisão injusta ou abuso policial, trataria de clamar inocência logo na primeira oportunidade de que dispusesse - até mesmo a fim de viabilizar a verificação, pela polícia investigativa, de eventual alibi -, sobretudo diante de tão grave imputação.

Mas não foi o que fez o réu, que preferiu permanecer em silêncio, pronunciando-se somente em Juízo, meses depois.

No contraditório, confessou a responsabilidade pelas drogas localizadas em seu poder, afirmando que destinadas ao seu consumo e dos rapazes que o acompanhavam. Contudo, essa singela negativa de autoria nem de longe restou comprovada pelo acusado, como lhe competia fazer, nos termos do que prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim é que quis fazer crer que foi conduzido à delegacia apenas em razão de seus antecedentes criminais.

Entretanto, essa versão não foi confirmada pelos indivíduos que o acompanhavam, que foram ouvidos em solo policial (págs. 15 e 16), e não foram arrolados como testemunhas de defesa no contraditório.

Todavia, acatar essa narrativa implicaria em reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos policiais, com o exclusivo objetivo de incriminar injustamente pessoa que sequer conheciam.

Por fim, se verídica a versão que apresentou em juízo, não haveria razão para que fosse omitida em solo policial.

Com efeito, o réu foi surpreendido enquanto trazia consigo drogas fracionadas, prontas para o comércio. Questionado, informalmente, admitiu que promovia a mercancia no local.

No mais, os policiais inquiridos deram conta da diligência que realizaram, que culminou na prisão em flagrante do acusado, que portava 29 porções de droga conhecida por K2.

E os esclarecimentos apresentados pelos policiais, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, os policiais prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois

negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas".(TJRJ – AC – Rel Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

De resto, o destino do tóxico apreendido é manifesto.

O réu portava 29 (vinte e nove) porções de ADB-Butinaca, substância conhecida como K2, altamente nociva e viciante, prontas para o comércio. E o réu foi visto pelos policiais mantendo contato com o ocupante de um veículo, e houve gesto de troca entre eles.

Logo, as circunstâncias da prisão e a forma como o tóxico estava acondicionado, afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei especial.

Assim não fosse, a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (TJSP – AC 9.751-3 – Rel. Gonçalves Sobrinho – RJTJSP 75/343).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente – Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização – Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível – Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76." (TJMT – AC 565/86 – Rel. Mauro José Pereira – RT 620/331).

E o réu não produziu uma única prova no sentido de que havia trabalhado naquele dia, de forma a demonstrar que dispunha de recursos para adquirir as porções da droga para mero consumo, o que disse fazer diariamente.

Demonstrada a ocorrência do delito, e comprovada a autoria, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

O acusado é reincidente específico, uma vez que registra condenação definitiva, oriunda da 4ª Vara Criminal desta capital, cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 03/07/2018 (págs. 63/65).

Logo, pelos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Pela reincidência comprovada, agravo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Em se tratando de réu reincidente, não estão presentes os requisitos do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

E não existe a desproporção no que diz respeito a dosimetria da pena, por conta da reincidência.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- Na hipótese sub exame, configurada a reincidência, posto persistente a tipificação do delito de posse para uso próprio, bem como não existe a necessidade que a condenação definitiva pelo delito anterior seja privativa de liberdade.

Precedentes.

- Possível a considerar a reincidência como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem, pois tal instituto possui finalidade jurídico-legal distinta em cada etapa de aplicação da pena, conforme expressa previsão legal.

- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas - 26 porções de crack e 1 (um) invólucro plástico de cocaína, (sabe-se que o crack é uma substância que possui um alto efeito devastador, devendo-se impor um maior rigor na apreciação da conduta do paciente) - , e a reincidência da paciente, justificam a imposição do regime inicial fechado, bem como a não substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido.". (HC 236982 SP 2012/0058827-2 Relatora: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE)).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra WESLEY RODRIGO DE SOUSA, R.G. nº 50.695.182, e o condeno ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos e oitenta e três dias multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista o que dispõe a Lei 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, §1º da lei 8.072/90.

Pela gravidade do crime, considerado hediondo, e pela comprovada reincidência, para garantia da ordem pública o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra, e igualmente não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que mostram-se presentes os fundamentos que justificaram a medida, reforçados pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal com o cumprimento da pena aqui aplicada (artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal).

Não é o caso de regime mais brando por força da prisão provisória (lei 12.736/12), uma vez que inaplicável o que dispõe o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alínea "b", da lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei. Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de julho de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA